

1501114-18.2021.8.26.0048

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... uma vez que é usuário, negando a prática de tráfico no local; não reconheceu como suas as demais drogas encontradas; saiu correndo ao avistar a viatura pois o local é ponto de tráfico e sabia que se fosse abordado, seria preso por tráfico; confirmou que o celular lhe pertencia, assim como a porção de cocaína e o dinheiro apreendido; alegou que havia recebido naquela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501114-18.2021.8.26.0048 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501114-18.2021.8.26.0048

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO FERRAZ DA ROCHA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

EDUARDO FERRAZ DA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 22 de maio de 2021, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia de Covid-19, por volta das 14h30min, na Rua Itororós, 375, Recreio Maristela II, em Atibaia, tinha em depósito para fins de tráfico ilícito, 10 porções de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, na data supra, o réu tinha as referidas porções de cocaína em depósito junto ao rodapé de um muro. Assim, ao avistar guardas municipais que passavam pela região, ficou nervoso e saiu correndo. Desconfiados de tal atitude suspeita, os agentes de segurança foram ao seu encalço e o abordaram. Então, o réu prontamente confessou que estava traficando e que havia dispensado, logo antes da fuga, os entorpecentes, dinheiro e um celular. Com efeito, os guardas encontraram atrás do muro uma porção da droga, a quantia de R\$ 341,00 e um celular.

A exordial narrou que os agentes foram ao local onde haviam avistado inicialmente o réu e ali encontraram as demais porções da droga, idênticas àquela encontrada anteriormente.

A denúncia (fls. 60/61) foi oferecida e o réu foi notificado (fls. 94), tendo apresentado defesa preliminar (fls. 118/124), a qual foi afastada por decisão afastou preliminar arguida e que recebeu a denúncia (fls. 133/136). O réu foi citado (fls. 175). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final (fls. 185/186).

Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 208/213).

A defesa requereu, em síntese, a desclassificação da conduta pela qual o réu foi denunciado para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, argumentando que não existe qualquer prova que condene o réu pelo crime de tráfico de drogas, já que os policiais não visualizaram a ocorrência da traficância. Aduziu que o réu apenas demonstrou nervosismo por já ter passado pela situação por duas vezes, tendo sido, inclusive, denunciado e processado pelo crime de tráfico de drogas, embora tenha sido absolvido, tratando-se de mero usuário de drogas. Argumentou que o pedido de condenação se baseia em achismo e que existe algo entre réu e testemunhas, uma vez que estas testemunharam em desfavor do acusado em outro processo. Alegou que o acondicionamento dos entorpecentes apenas demonstra que eles foram comprados naquele lugar, não que o réu seria proprietário das drogas encontradas num muro distante. Invocou o princípio in dubio pro reo para postular a absolvição do acusado, reafirmando não existir qualquer prova absoluta que demonstre que o réu estivesse traficando. Para o caso de condenação, a defesa postulou o afastamento da agravante relativa à calamidade pública (fls. 217/223)

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 03/05), no auto de exibição e apreensão (fls. 09), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 10), no laudo toxicológico (fls. 31/32) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente (fls. 50), confessou que comprou uma porção de cocaína, uma vez que é usuário, negando a prática de tráfico no local; não reconheceu como suas as demais drogas encontradas; saiu correndo ao avistar a viatura pois o local é ponto de tráfico e sabia que se fosse abordado, seria preso por tráfico; confirmou que o celular lhe pertencia, assim como a porção de cocaína e o dinheiro apreendido; alegou que havia recebido naquela data o valor de R\$ 370,00 em virtude de seu trabalho, sendo que gastou R\$ 9,00 numa garrafa de cerveja e R\$ 20,00 num papelote de cocaína, restando em seu poder o valor de R\$ 341,00.

Posteriormente, o réu ratificou todas as suas declarações anteriores (fls. 46), afirmando, ainda, que o lugar da abordagem é próximo de sua residência e por tal motivo estava no local; na ocasião, estava com outra pessoa, de quem adquiriu as drogas, não tendo sabido, entretanto, identificar tal indivíduo pelo nome ou outros dados.

Em juízo, o réu negou a prática do tráfico; alegou que tinha acabado de sair do serviço, num sábado, por volta do meio-dia; como sua residência é próxima do bar, passou pelo local e comprou uma porção de cocaína por R\$ 20,00 e uma garrafa de cerveja, no valor de R\$ 9,00; o que pegaram em seu bolso foi o dinheiro que tinha acabado de receber, seu telefone celular e a porção de cocaína que havia acabado de comprar, sendo que ia entrar em sua casa e fazer o consumo; há alguns menores do lado do bar, os quais ficam traficando; indagado sobre o motivo pelo qual está sendo acusado por tráfico, respondeu que foi levado para a Delegacia por tráfico, sendo que pegaram com sua pessoa uma porção; apareceram com mais nove porções, afirmando que eram suas; indagado sobre de onde foram tiradas as demais porções, respondeu que foram no terreno baldio existente na frente e voltaram, mas tais nove porções somente apareceram na Delegacia; questionado sobre o fato de as nove porções serem idênticas àquela encontrada em seu poder, respondeu que havia

comprado sua porção naquele local; indagado sobre ter dito que menores ficam no local vendendo, mas que não havia ninguém além de sua pessoa, respondeu que havia alguém no bar sim, e que embora tenham dito que o bar estava fechado, a verdade é que ele estava aberto; questionado sobre estar sendo incriminado injustamente por pessoas que sequer o conheciam, respondeu que o conheciam sim, explicando que já foi abordado por cerca de cinco vezes, uma vez que sua residência fica ao lado do bar; trabalhava no Jardim dos Pinheiros, sendo que seu patrão se chamava Leandro; indagado sobre o motivo pelo qual o dinheiro estava trocado, respondeu que não havia dinheiro trocado; tinha R\$ 41,00, compostos por duas notas de R\$ 20,00 e uma moeda de R\$ 1,00; tem passagem por tráfico de drogas, do ano de 2015 e 2016; ostenta, também, desacato e Maria da Penha; ficou dez meses preso por conta do desacato; estudou até a sexta série; atualmente trabalha com piscinas e auferir R\$ 120,00 por dia trabalhado, sendo que trabalha cinco dias por semana; pela defesa do acusado, foi indagado se os policiais foram as mesmas testemunhas de acusação do processo pelo qual havia acabado de sair da prisão, respondeu que sim; saiu da prisão porque foi absolvido; indagado se sua residência ficava próxima ao local, respondeu que sua casa fica ao lado do bar; questionado se tinha alguma coisa contra os policiais, respondeu que sim, pois já foi abordado por várias vezes e invadiram sua casa sem mandado, sem nada; questionado pelo juízo sobre o motivo pelo qual saiu com R\$ 370,00 de casa, já que mora ao lado do bar e foi comprar apenas uma cerveja e uma porção de cocaína, respondeu que não saiu de casa; tinha acabado de sair do serviço, entrou no bar e estava voltando para sua casa; estava há 15 dias na rua e não ia ficar na frente do bar.

A testemunha André Luiz dos Santos Pinto, guarda municipal, disse que estavam em serviço e, em patrulhamento por região conhecida pelo tráfico de drogas, descendo pela Avenida Pacaembu, visualizaram um indivíduo abaixado, num canto, ao lado de um bar, mexendo em alguma coisa; desembarcou da viatura com um parceiro, sendo que um terceiro agente permaneceu no veículo para dar a volta e evitar eventual fuga; assim que o indivíduo os visualizou, ele empreendeu fuga por determinada via, entrando, então, num recuo; a viatura os alcançou e, neste momento, o indivíduo saiu para a rua novamente; o motorista acelerou e o abordaram; em revista pessoal, não encontraram nada com o réu, mas ele confessou que havia guardado uma porção de cocaína naquele recuo, dentro de um muro; com efeito, localizou a porção em um dos furos do muro; por cima do muro havia uma quantia de dinheiro, aproximadamente R\$ 350,00 em notas trocadas; o réu arremessou o celular para dentro do quintal de uma residência, o qual alcançou, devido à altura do muro; questionado, o réu confessou que havia entrado naquele local para esconder a porção de cocaína e que estava no tráfico; seu colega voltou até o local em que o acusado estava abaixado e encontrou outras nove porções da mesma substância, idênticas àquela encontrada em poder do réu; o réu afirmou que estava nas ruas havia 15 dias e estava necessitado de dinheiro, motivo pelo qual estava traficando; na Delegacia, entretanto, o réu negou a prática; pela defesa do acusado foi indagado se a testemunha se recordava se o réu residia próximo ao local dos fatos, ao que respondeu não se recordar; indagado sobre o que foi encontrado com EDUARDO, respondeu que não se recordava, mas afirmou que o que encontraram atrás do muro, ou seja, o dinheiro e a cocaína, o réu confessou ser dele; indagado se encontraram alguma coisa no local em que o réu estava antes de ter sido abordado, reafirmou que encontraram nove porções de cocaína, encontradas por seu motorista, Leme; indagado se o local onde o réu foi avistado primeiramente era um bar, respondeu que há um bar no local, onde já apreenderam menores e prenderam maiores de idade em virtude do tráfico de entorpecentes, mas no dia em questão não havia mais ninguém e o bar estava fechado; indagado sobre em que locais usuários comprem entorpecentes, respondeu que em diversos locais, inclusive no local dos fatos; indagado se usuários e traficantes frequentam o mesmo local, conhecido por "biqueira", respondeu que naquele dia, EDUARDO estava acondicionando as drogas no local e não havia ninguém que pudesse estar comprando; questionado se o local em que as nove porções foram encontradas é acessível a terceiros, respondeu que viram o réu abaixado no local e seu motorista afirmou que as drogas estavam escondidas no canto, de modo que se terceira pessoa passasse por ali, não visualizaria; indagado se todos foram em perseguição ao réu

durante a fuga e depois voltaram ao local em que ele estava abaixado, ou se alguém permaneceu naquele primeiro local, respondeu que estavam a curta distância do local de onde o réu partiu e que estavam a todo momento de olho, para que ninguém pudesse se aproximar; indagado se as drogas encontradas estavam embaladas da mesma forma que o entorpecente apreendido com o réu, respondeu que sim.

A testemunha Luís Henrique Cometti Leme, guarda municipal, disse que durante patrulhamento pelo bairro Imperial, avistaram EDUARDO ao lado de um bar, onde há um muro, sendo que o réu estava pegando algo atrás de tal muro; seus dois companheiros de trabalho desembarcaram e o réu empreendeu fuga; deu a volta com a viatura e EDUARDO entrou numa espécie de beco, um recuo de uma casa, onde ele dispensou um celular, uma quantia em dinheiro em cédulas trocadas e uma porção de cocaína; assim que o abordaram, o réu disse "Perdi! Perdi!" e confessou a prática da traficância naquele local; voltou ao local onde o réu estava abaixado, que é na mesma rua, próximo de onde ele foi abordado, e encontrou nove porções da mesma substância que o réu dispensou; havia diversas denúncias que apontavam EDUARDO como traficante daquela região, mas não foi elaborado flagrante na Delegacia; dias depois, o réu foi abordado naquele mesmo local, sendo que nada foi encontrado, mas tão somente uma quantia em dinheiro; ao indagá-lo sobre o tráfico da oportunidade anterior e sobre a traficância empreendida naquele momento, o réu afirmou que o mundo é dos espertos e por tal motivo ele estava na rua mais uma vez; em outra oportunidade, juntamente com a polícia civil, o réu novamente confessou a traficância, mais uma vez estava com dinheiro e apontou o local onde ele armazenava as drogas, tendo sido capturado pela SIG da Polícia Civil; depois dos fatos, por várias vezes o réu estava no mesmo local traficando, tendo havido denúncias, mas não tiveram êxito em encontrá-lo com entorpecentes, mas ele sempre estava com cédulas trocadas no bolso; indagado sobre o horário em que o encontrou nas outras oportunidades, respondeu que não sabia precisar o horário exato, mas seu intervalo de trabalho é das 13h às 01h; questionado, quanto ao processo ora sob julgamento, se as nove porções encontradas eram do mesmo tipo de entorpecente e se estavam em embalagens iguais, respondeu que eram idênticas àquela dispensada pelo réu, que assumiu a traficância no momento da abordagem, tendo ainda indicado o local em que encontraria mais drogas, o que de fato ocorreu; indagado se o réu assumiu a propriedade também das nove porções posteriormente encontradas, respondeu que sim, confirmando que pertencia a ele; pela defesa do réu foi indagado se o depoente já foi testemunha em outros processos contra EDUARDO, ao que respondeu que sim, no caso que envolveu a SIG; indagado se o local em que as nove porções foram encontradas é movimentado, respondeu que referido local fica na rua Itororó, a duas casas de distância do bar, tratando-se de local em que dificilmente uma pessoa se abaixa para pegar alguma coisa, não havendo hipótese de algum terceiro ter colocado algo naquele local; indagado se havia outras pessoas naquele local, respondeu que não; o bar estava fechado e só havia EDUARDO na rua, o que acabou chamando a atenção, pois ele estava enfiando a mão no muro quebrado; questionado se ao perseguirem o réu, alguém ficou no local em que o acusado foi visto abaixado, respondeu que estavam, no máximo, a trinta metros de distância do local em que o réu estava abaixado, então não havia necessidade de alguém guardar aquele local, sendo que ninguém se aproximou ou adentrou a rua no momento em que efetuavam a abordagem; indagado se sabia se o réu residia próximo àquele local, respondeu hoje saber, pois cumpriu uma diligência junto com o SIG na casa do acusado, mas naquele dia não tinha conhecimento de que o acusado morava próximo àquele local; indagado se naquela região há outra pessoa chamada Eduardo, respondeu que havia uma pessoa, sobre quem existia denúncias, cuja alcunha era "Duca"; as denúncias a respeito do réu versavam sobre EDUARDO, cujo vulgo é "Lerdão"; indagado se usuários e traficantes frequentam o mesmo local, respondeu que por ser um ponto de tráfico, o local é movimentado por usuários e traficantes; indagado a respeito de quantas vezes já abordou o réu naquele local, respondeu que após a ocorrência ora em análise, abordou o réu por mais uma ou duas vezes, sendo que ele sempre estava com notas trocadas; afirmou que a própria esposa do réu encontrou com sua pessoa na rua e disse que acreditava que o réu sairia dessa e que EDUARDO havia prometido que não mais praticaria o tráfico; indagado pelo Juízo se antes da ocorrência sob análise já havia abordado o réu, respondeu que não.

Pois bem.

O réu negou a prática delitiva em ambas as oportunidades nas quais foi ouvido. Afirmou, em suma, que havia acabado de sair do trabalho, tendo passado no bar para comprar uma cerveja por R\$ 9,00 e adquirido uma porção de cocaína por R\$ 20,00, alegando que consumiria tais itens em sua casa, que fica ao lado do bar em questão. EDUARDO negou qualquer relação com as nove porções de cocaína encontradas no muro existente no local, argumentando que a porção que possuía era semelhante àquelas encontradas porque havia adquirido a droga naquela localidade, tendo afirmado, ainda, que embora tenham dito que o bar estava fechado o fato é que o estabelecimento estava aberto.

Em solo policial afirmou que correu porque sabia que seria preso por tráfico caso fosse abordado no local, uma vez que se trata de ponto de traficância.

Alegou, em juízo, que os agentes o conheciam e que já havia sido abordado pelo menos cinco vezes, sendo que já invadiram sua casa mesmo sem mandado.

O fato, entretanto, é que a narrativa do acusado não se sustentou e acabou isolada nos autos.

A uma porque embora tenha dito que comprou uma garrafa de cerveja por R\$ 9,00, o fato é que tal garrafa não foi apreendida e não constou de nenhum termo relacionado à ocorrência.

A duas porque embora tenha relatado que o bar não estava fechado e que comprou o entorpecente no local, o réu não foi capaz de mencionar nada sobre quem teria lhe vendido a porção de droga que tinha consigo, limitando-se a afirmar que o bar estava aberto e que alguns adolescentes ficam ali efetuando a venda de drogas.

E a três porque o réu não foi capaz de infirmar a narrativa das testemunhas guardas municipais ouvidas, as quais esclareceram a dinâmica da ocorrência com segurança e linearidade.

Ambos os agentes afirmaram que durante patrulhamento pela região, conhecida pelo tráfico de drogas, visualizaram o réu abaixado num canto, ao lado de um bar, mexendo em alguma coisa num muro ali existente. Disseram que ao desembarcarem da viatura e se aproximarem para verificar o que estava acontecendo, o réu empreendeu fuga e entrou num recuo.

Os agentes relataram que quando o acusado saiu novamente para a rua, abordaram-no e nada encontraram em seu poder. Entretanto, disseram que o réu confessou que havia guardado uma porção de cocaína naquele recuo, dentro de um muro.

Com efeito, os agentes encontraram a porção da droga, além de aproximadamente R\$ 350,00 em notas trocadas e um celular, que o réu havia arremessado para dentro do quintal de uma residência.

No local onde o réu esteve abaixado anteriormente, os agentes afirmaram que foram encontradas outras nove porções de cocaína, embaladas de forma idêntica àquela encontrada no recuo para onde o réu se afugentou.

Ambos os guardas confirmaram que o réu confessou que estava praticando o tráfico no local. Além disso, os agentes também relataram que não havia mais ninguém na localidade além do acusado, bem como que o bar estava fechado.

O agente Luís Henrique asseverou ter sido o responsável por voltar ao local onde o réu esteve abaixado anteriormente, que era próximo à localidade em que o réu foi abordado. Confirmou ter encontrado nove porções de cocaína embaladas da mesma forma que aquela encontrada no recuo para onde o réu fugiu.

Referida testemunha ainda relatou que havia diversas denúncias que apontavam EDUARDO como traficante daquela região, tendo confirmado que o conhecia de outras ocorrências. A testemunha afirmou que ao perguntar para o réu sobre a prática do tráfico em oportunidade anterior, obteve por resposta que "o mundo é dos espertos".

Luís Henrique relatou que em outra oportunidade, juntamente com a polícia civil, o réu novamente confessou a traficância, mais uma vez estava com dinheiro e apontou o local onde ele armazenava as drogas, tendo sido capturado pela SIG da Polícia Civil, e que depois de tais fatos, por várias vezes, o réu estava no mesmo local traficando, tendo havido denúncias. A testemunha relatou, entretanto, que não conseguiram, nestas outras oportunidades, encontrá-lo com entorpecentes, mas tão somente com cédulas trocadas no bolso.

O que se extrai da prova formada, portanto, é que acusado procurou, com sua

narrativa, tornar as testemunhas guardas municipais suspeitas de perseguição, uma vez que já teria sido abordada anteriormente pelos agentes. O fato, entretanto, é que a testemunha Luís Henrique confirmou que já abordou o réu em outras oportunidades, sendo certo que em todas elas, o réu portava tão somente dinheiro trocado.

Não há, desta forma, motivo para crer que o agente simplesmente imputaria falsamente o delito de tráfico ao réu, já que em outras oportunidades de abordagens não o fez, limitando-se a verificar que o réu portava tão somente dinheiro.

Ocorre que na oportunidade narrada nos presentes autos, o réu foi flagrado mexendo num muro e, ao notar que foi visto por agentes da Guarda Municipal, fugiu para um recuo na rua, onde abandonou uma porção de cocaína, dinheiro trocado e um telefone celular. No local em que esteve mexendo no muro, os agentes encontraram outras nove porções de cocaína idênticas àquela que o réu escondeu no recuo.

Os agentes ainda asseveraram que não havia outras pessoas no local, bem como que o bar estava fechado, não havendo, desta forma, como o réu ter comprado aquela porção que escondeu de outra pessoa. Ademais, por não ter passado mais ninguém por aquele local, não poderiam, as nove porções encontradas no muro onde o réu foi visto antes de fugir, ser de outra pessoa.

A verdade é que as porções encontradas no local onde o réu foi visto abaixado, mexendo no muro, bem como aquela encontrada no recuo, eram do acusado. E é fato que o réu não comprou uma cerveja, como alegou ter feito, já que ela não foi sequer mencionada pelos agentes, não constando, ainda, de qualquer termo dos autos.

Ademais, não faria sentido em se crer que o réu teria simplesmente fugido da abordagem policial com uma cerveja e uma porção de cocaína em direção a um recuo da via, sendo certo que confirmou morar ao lado do bar; se nada estivesse escondendo, o réu simplesmente poderia ter ido para sua própria casa, coisa que não fez.

Assim, a narrativa do réu se mostrou isolada nos autos, tendo sido, ainda, infirmada pelo seguro relato das testemunhas guardas municipais ouvidas.

É conveniente rememorar que os depoimentos judiciais de guardas municipais e policiais, sejam civis ou militares, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por guardas municipais ou policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade.

Neste sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME DE DESACATO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. Depoimentos dos guardas municipais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Em uma atuação secundária, cabe aos guardas municipais a preservação da ordem pública, a qual é responsabilidade de todos, sendo imposta aos órgãos de segurança o dever legal. Desta forma, é conferida à guarda municipal a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal. Precedentes do STJ

(...)” (TJ-SP - APL: 00059693020128260372 SP 0005969-30.2012.8.26.0372, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 26/02/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/03/2015) (destaquei).

Nem se diga, ainda, existir ilegalidade na ação empreendida pelos Guardas Municipais por ocasião dos fatos, seja em relação à busca pessoal ou mesmo à condução do acusado à Delegacia de Polícia.

Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à realização de tal tarefa, incluindo-se a prisão, pelos mencionados servidores públicos, ainda que tal carreira não conste, de forma expressa, do rol constante do art. 144, da Constituição Federal. Trata-se, pois, de faculdade conferida a qualquer povo, além de representar um ato que objetiva a proteção da segurança social.

Assim já se decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada”. (STJ - HC: 129932 SP 2009/0035533-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2010).

E ainda:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade de prisão em flagrante, porque efetuada por guardas municipais de trânsito, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido”. (STJ - RHC: 14585 SP 2003/0102527-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Publicação: DJe 08/08/2005).

Mesmo que assim não fosse, não há que se falar, tecnicamente, em nulidade na fase de inquérito, mas apenas eventual irregularidade, condição esta que não tem o condão de contaminar ou viciar a ação penal que lhe sucedeu.

E não há como defender a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O artigo 33 da Lei 11.343/06 não define como necessário, para a consumação das figuras típicas em questão, o caráter comercial do tráfico. Aliás, sequer delimita qualquer definição para “traficante”, limitando-se a descrever figuras típicas que, praticadas, ensejam penalidade.

In verbis:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” (Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006).

Optei por destacar, na transcrição acima, justamente a conduta descrita na denúncia, a qual foi perpetrada pelo réu, bem como o restante do dispositivo, restando evidenciado que não há, na Lei, qualquer menção sobre a necessidade de se evidenciar a finalidade mercantil do entorpecente.

A ação descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 dispõe que “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”

(destaquei e grifei), estará sujeito às sanções previstas naquele dispositivo.

Este artigo, sim, aponta uma finalidade específica: o consumo pessoal. Assim, a

comprovação de que a droga era destinada ao consumo pessoal cabe àquele que assim alega, conforme a regra estampada no artigo 156 do Código de Processo Penal. O réu não se desincumbiu de tal ônus, não tendo formado mínima prova a respeito do alegado consumo de drogas que fazia.

E ainda que o réu comprovasse algum consumo de entorpecentes – o que não fez, repiso –, é comum que o usuário do entorpecente faça do tráfico a fonte de sustento de seu vício. Assim sendo, ainda que o réu houvesse comprovado algum consumo de entorpecente, o fato é que uma atividade não exclui a outra. E as circunstâncias em que o acusado foi flagrado, bem delineadas pelas testemunhas agentes de segurança pública, não denotam se tratar, o réu, de mero usuário, mas sim de praticante do tráfico ilícito de entorpecentes.

O laudo pericial acostado ao processo, a fls. 31/32, apontou a apreensão de cocaína, substâncias de uso proscrito no Brasil.

O dinheiro apreendido não teve sua origem esclarecida a contento pelo acusado que, embora tenha alegado que auferia R\$ 120,00 por dia trabalhado, trabalhando cinco dias por semana, com piscinas, asseverou em solo policial que trabalhava como pedreiro, auferindo R\$ 370,00 por semana (fls. 48), não tendo sido capaz de explicar o motivo pelo qual estaria na rua com todo o valor que teria recebido pelo trabalho semanal como pedreiro – ignorando-se a versão judicial de que auferia R\$ 120,00 por dia trabalhado com piscinas –, não havendo segurança sobre qual seria a verdadeira atividade empreendida pelo acusado, segundo suas próprias versões.

A existência de discrepâncias a respeito do valor que o réu auferia com suposto trabalho lícito e a ausência de qualquer comprovação neste sentido comprovam, em verdade, que o dinheiro apreendido era proveniente da prática ilícita que efetuava. É o quanto basta para restar caracterizada a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Reconhecida a autoria, passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu ostenta mais de uma condenação apta a ensejar sua reincidência, de modo que uma delas, a estampada a fls. 83 (processo 0000697-16.2015.8.26.0545, condenação transitada em julgado aos 06 de março de 2017) o onerará em forma de maus antecedentes, e a outra, em fase própria de dosimetria.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. (...) 4. É pacífica a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 5. Este Sodalício orienta que não configura bis in idem ou inconstitucionalidade, quando, reconhecidas múltiplas reincidências, o sopesamento, na fixação da condenação, de uma na primeira fase, para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes (art. 59, CP), e de outra na segunda fase, como circunstância agravante (art. 63, CP) (...). (STJ - HC: 215126 MS 2011/0183443-9, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) (destaquei).

É rigor destacar, ainda, que embora tenha havido a concessão de indulto de tal pena aos 21 de agosto de 2019, é fato que, conforme jurisprudência dominante, o indulto

atinge tão somente a pretensão punitiva estatal, não interferindo sobre os outros efeitos da sentença condenatória – entre eles a reincidência e os maus antecedentes.

No mais, culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Pouco se colheu a respeito de sua personalidade. Com relação à conduta social do acusado, de rigor considerar que a testemunha Luís Henrique afirmou que já conhecia o réu de outras abordagens na localidade, tendo afirmado, inclusive, que havia denúncias a respeito da traficância empreendida pelo réu naquele ponto de tráfico. É aspecto importante e desabonador quanto à conduta social do acusado. Quanto aos motivos do crime, os comuns à traficância. Quanto à natureza e quantidade do produto, foram apreendidas 10 porções de cocaína.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, diária mínima, considerando a ausência de comprovações a respeito da renda alegada pelo réu, a qual restou infirmada pelo próprio relato do réu em solo policial. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, incidem as agravantes relativas à reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) e o fato de o réu ter cometido o crime em ocasião de calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea “j”).

O réu ostenta condenação pretérita ensejadora de reincidência, conforme se observa da certidão acostada a fls. 84 (processo 1500212-97.2019.8.26.0545, cuja sentença condenatória transitou em julgado aos 30 de janeiro de 2020, tendo havido trânsito em julgado da sentença que extinguiu a pena do acusado, conforme certidão de fls. 87, aos 03 de maio de 2021, não tendo decorrido o prazo depurador de cinco anos entre a extinção de referida pena e o cometimento do novo delito). Não obstante, fez-se presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal, uma vez que o crime foi praticado durante a vigência de estado de calamidade, o qual foi decretado em março de 2020, não havendo que se discutir ter o réu se beneficiado ou não da condição para a prática delitiva, uma vez que a Lei não faz tal distinção. A pena é agravada e atinge, ao final da segunda fase de dosimetria, 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 720 dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento de pena. Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O réu é reincidente, o que impede objetivamente a concessão do benefício.

Destarte, a pena definitiva é fixada em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 720 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena será o fechado, considerando o fato de que se trata de réu reincidente, que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Além disto, de se considerar que o tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização – sobre o óbvio, diga-se –, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática – a tão altos custos – permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão

narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto e porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminoso ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênua, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um

revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)" (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno EDUARDO FERRAZ DA ROCHA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 720 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

O réu respondeu ao processo em liberdade e, não havendo circunstância apta a ensejar sua prisão preventiva, poderá apresentar eventual recurso em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. EXPEÇA-SE, OPORTUNAMENTE, MANDADO DE PRISÃO.

Decreto a perda, em favor do FUNAD, do valor em dinheiro apreendido nos autos, uma vez não comprovada a sua origem lícita. Após o trânsito em julgado, oficie-se para levantamento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade da Justiça.

P.I.C.

Atibaia, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA